

以憲法解釋方法試論我國性自主權*

林慧婷**

* 東吳大學 114 學年度第 2 學期，課程名稱：憲法專題研究（四），授課老師：湯德宗 教授，報告日期：115 年 6 月 15 日。

** 東吳大學法律學系碩士班公法組二年級，學號：13341323。

目錄

壹、前言	1
貳、性自主權的憲法定位	1
一、性自主權的概念意涵.....	1
(一) 性自主權	1
(二) 性自主權具憲法價值	2
二、性自主權的憲法保障基礎.....	3
參、我國憲法解釋中的性自主權	3
一、性自主權於憲法解釋中之演變.....	3
(一) 釋字第 554 號解釋	3
(二) 釋字第 617 號解釋	4
(三) 釋字第 666 號解釋	5
(四) 釋字第 791 號解釋	5
二、大法官運用的解釋方法分析.....	6
(一) 概括基本權的解釋侷限	6
1. 文本主義 (Textualism)	6
2. 原旨主義 (Originalism)	7
(二) 大法官解釋方法的運作模式.....	7
1. 文本主義與原旨主義.....	7
2. 共識主義 (Consensualism)	8
3. 哲學方法 (the Philosophic Approach)	9
肆、未來對性自主權之態度	10
一、無法擺脫的解釋困境.....	10
二、可能的解釋方向預測.....	10
(一) 釋字 617 號解釋與釋字 666 號解釋的再續.....	10
(二) 侵害性自主權的認定與加重刑罰	11
伍、結論	11
參考文獻	13

壹、前言

通姦除罪的議題在我國爭議已久，故釋字 791 號解釋一作成即引發熱議，其中大法官們首次於解釋文中明確使用「性自主權」一詞，但其實在過去的大法官解釋中早已多次觸及相關概念。如我國近年的憲法實務中，同樣處理婚姻家庭保障的釋字 554 號解釋、涉及猥褻物品管制的釋字 617 號解釋到性交易處罰的釋字 666 號解釋，顯見大法官對個人在性領域的自主決定並非毫無權衡。釋字 791 號解釋作成後，雖確立了性自主權憲法層級的地位，並宣告通姦罪違憲，但我國對性自主權之討論依舊留有大片空白，大法官們在釋字 791 號解釋中將性自主權簡化為「性行為自由」，即個人與何人、在何時、以何種方式發生性行為的自由。然而，性自主權是否僅止於此種消極不受干預的身體自由？又性自主權作為一項並未明文見於憲法文本的「概括基本權」，其在解釋上是否仍有「文本主義」或「原旨主義」的適用餘地？當「當代」的大法官面對「制憲當時」並未預見的性觀念，勢必得在文本限制與時代演進之間重新找尋適用的平衡點。

須先敘明，本文雖將性自主權定位於憲法第 22 條之概括基本權，然並非探討該條項下所有概括基本權之類型與保障，而係專注於性自主權之法理。同理，本文後續引述釋字第 554 號與第 791 號解釋，其關注點亦在於解析大法官對「性自主權」本身之論述流變與方法論運用；至於婚姻自由之保障範圍、通姦除罪化之社會利弊以及婚姻家庭制度之社會功能或重要性等解釋中涉及的其他議題，則非本文欲處理之範疇。

綜上，本文將以憲法解釋方法探討性自主權此一「新型態基本權」，重新檢視其概念內涵、保障範圍，並以我國大法官解釋的歷史變遷作為中心，分析從釋字 554 號、617 號、666 號至釋字 791 號解釋發生的典範轉移，並探討於此變遷過程中，大法官在不同時期所運用的解釋方法，並嘗試預測性自主權未來於我國憲法領域可能的發展與困境。

貳、性自主權的憲法定位

一、性自主權的概念意涵

（一）性自主權

按釋字第 791 號解釋理由書認定通姦罪「禁止有配偶者與第三人間發生性行為，係對個人得自主決定是否及與何人發生性行為之性行為自由，亦即性自主權，

所為之限制」可知該號解釋似乎將性自主權直接等同於性行為自由，並將其解釋為「自主決定是否及與何人發生性行為」之自由¹，然而所謂「性自主權」，應先拆分為「性」及「自主權」兩部分，其中「自主權」，係指對於一定之重要私事或個人事項，不受公權力干涉，而可以自主決定之權利²，而「性」則表示發生於性領域，故性自主權，應解釋為人民於個人性領域之自主決定權。

許志雄大法官則提出性自主權有廣義與狹義之分，除了狹義的性行為自由，廣義之性自主權應包含結婚以及相關連之妊娠、生產與墮胎自由，而釋字第 554 號解釋及釋字第 791 號解釋所闡述之「自主決定是否及與何人發生性行為之性行為自由，亦即性自主權」即採取狹義性自主權之見解。

我國大法官亦曾就性自主權所涵蓋之範圍進行較完整之論述³，主張性自主權保障個人對於諸如個人性別認同與性傾向、性觀點、性生活之對象、時間、地點及方式、乃至於是否基於對價關係而從事性行為等性領域之事項得自主決定之權利。不僅保障消極性自主權，亦包含積極性自主權，以狹義性自主權之「性行為自由」為例，消極性自主權即具防禦功能，人民得拒絕或決定不發生性行為。

（二）性自主權具憲法價值

關於性領域，我國憲法實務已於釋字第 666 號解釋肯定性言論與性資訊之憲法價值，許玉秀大法官並於其提出之意見書進一步說明性言論自由與性資訊流通自由應受保障之原因，在於其有利於個人發展完整人格、形成實現自我所必備的自主意識與自我決定權。當性言論與性資訊之憲法價值獲得肯定後，便可達成養成性自主意識（性權利主體意識）與實現性自我決定權之目的。

當自主決定之自由獲得保障，得依其個人意志發揮，個人之人格方能健全發展，自主決定之價值在於「自主決定」本身，而非對決定後之結果加以評價，換言之，自主權之所以應受保障，係因該決定行為出自自由意志，而非因該決定符合某種普遍性原則而顯得正確無誤。性自主權既係個人在性領域的自主決定權，其同樣具備憲法價值，應屬無疑。

¹ 學者葉啟洲亦持類似論述，認為性自主權之意涵在於「自由決定是否發生性行為、性行為之對象以及如何發生性行為」，參見葉啟洲，通姦罪違憲論的初始觀點—大法官釋字第 554 號解釋的聲請典故，台灣法學雜誌，392 期，頁 43-47，2020 年。

² 參見釋字第 791 號解釋許志雄大法官提出之協同意見書（第 6 頁）。

³ 參見釋字第 666 號解釋林錫堯大法官、陳敏大法官、陳春生大法官共同提出之協同意見書（第 7 頁）。

二、性自主權的憲法保障基礎

承上所述，性自主權既具憲法價值，自應與其他基本權一般同受憲法保障，然我國憲法並未有明文保障性自主權（或性行為自由），僅有憲法第 22 條⁴作為未列舉基本權之保障依據。因而無論是釋字第 554 號解釋或釋字第 791 號解釋，在闡述性自主權（包含性行為自由）係屬憲法所保障之權利時，均援引憲法第 22 條此一概括條款作為其論述依據。

於比較法之觀點上，德國學界對於性自主權之憲法依據同樣被劃分於補遺性基本權，學理上多將其列入一般人格權保障，與人性尊嚴相同，以權力主體之主體性為保障重點，認為個人性領域係屬不可侵犯之私密領域，具有性目的傾向之行為，係受到基本法第 2 條第 1 項⁵與第 1 條第 1 項⁶之自主保障，屬於人格最私密之範圍，僅能在面對特別之公共利益時始得受限。

由此可知，性自主權非受絕對保障，若為維護公益之必要，得為一定程度之限制，各國法制常設有妨害性自主罪、妨害風化罪，以及關於性騷擾、未成年人之性剝削、性工作者與性交易行為之防制及管制規定，於我國刑法第十六章制定之妨害性自主罪，即屬刑法上落實憲法對於性自主權保障（尤其針對消極性自主權）之具體規定。

參、我國憲法解釋中的性自主權

一、性自主權於憲法解釋中之演變

（一）釋字第 554 號解釋

釋字第 554 號解釋係為處理刑法第 239 條規定之通姦罪⁷是否違憲，該規定禁止有配偶者與第三人間發生性行為，以刑罰手段限制有配偶之人與第三人間之性行為自由，聲請人主張該規定已侵害人民之性自主權，大法官經審理後，認該

⁴ 中華民國憲法第 22 條：「凡人民之其他自由及權利，不妨害社會秩序公共利益者，均受憲法之保障。」

⁵ 德意志聯邦共和國基本法第 2 條第 1 項：「人人於不侵害他人之權利或不牴觸憲政秩序或道德規範之範圍內，享有自由發展其人格之權利。」

⁶ 德意志聯邦共和國基本法第 1 條第 1 項：「人之尊嚴不可侵犯，尊重及保護此項尊嚴為所有國家權力之義務。」

⁷ 釋字第 554 號解釋作成時應適用民國 91 年修正之版本，刑法第 239 條：「有配偶而與人通姦者，處一年以下有期徒刑。其相姦者亦同。」該規定已於 110 年 5 月 31 日修正之版本刪除。

規定對人民性行為自由之限制仍在比例原則之內，故該規定應屬合憲。

大法官於本號解釋中，雖未明確引用聲請書中「性自主權」一詞，但仍論及「性行為自由」，根據解釋文與理由書內容，大法官認為性行為自由係指「自主決定是否及與何人發生性行為」，且與個人之人格有不可分離之關係，應受憲法第 22 條之概括基本權保障，但同時應依循第 22 條所規定之要件，需於「不妨害社會秩序公共利益之前提下」始受保障，故人民之性行為自由應受婚姻與家庭制度之制約。本號解釋雖未提及性自主權，且最終對於通姦罪作成合憲解釋，但係我國大法官首次肯定人民具有「性行為自由」，且該自由權利受憲法保障，為後續解釋奠定基礎。

（二）釋字第 617 號解釋

釋字第 617 號解釋係為處理刑法第 235 條規定之傳播猥褻物品罪⁸是否違憲，該規定禁止人民傳播猥褻物品，以刑罰手段限制性言論之表現與性資訊之流通，聲請人主張該規定已侵害人民之言論及出版自由，大法官經審理後，認該規定對人民言論及出版自由之限制尚符比例原則之要求，故該規定於特定要件⁹下仍屬合憲。

大法官於本號解釋中，雖未直接將性自主權作為核心審查基礎，亦未在解釋文或理由書中有任何直接涉及「性自主權」之論述，但大法官點出該規定涉及之自由權利係「性言論自由與性資訊流通自由」，受憲法第 11 條言論及出版自由保障，惟仍應基於社會多數人普遍認同之性觀念或性道德感情予以合理限制。許玉秀大法官亦於其提出之意見書中對「性自主意識」有所闡述，肯定性言論自由與性資訊流通自由對性人格乃至完整人格的發展有所助益，並說明其所欲實現之目的，正是性自主意識（性權利主體意識）的養成與性自我決定權的實現¹⁰。故本

⁸ 刑法第 235 條：「（第一項）散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科九萬元以下罰金。（第二項）意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。（第三項）前二項之文字、圖畫、聲音或影像之附著物及物品，不問屬於犯人之與否，沒收之。」

⁹ 大法官將該條文規範之行為限定為「對含有暴力、性虐待或人獸性交等而無藝術性、醫學性或教育性價值之猥褻資訊、物品為傳布，或對其他足以刺激或滿足性慾，而令一般人感覺不堪呈現於眾或不能忍受而排拒之猥褻資訊、物品，未採取適當之安全隔絕措施（例如附加封套、警告標示或限於依法令特定之場所等）而為傳布，使一般人得以見聞之行為」，亦即俗稱之「硬蕊／軟蕊二分法」。

¹⁰ 參見釋字第 617 號解釋許玉秀大法官提出之不同意見書（第 1-2 頁）。

號解釋雖看似與性自主權無關，但大法官肯定我國保障「性言論自由與性資訊流通自由」，其概念應屬性自主權之一環，亦可認為大法官有將性自主權附屬於其他基本權（即言論及出版自由）之可能。

（三）釋字第 666 號解釋

釋字第 666 號解釋係為處理社會秩序維護法第 80 條第 1 項第 1 款「罰娼不罰嫖」之規定¹¹是否違憲，該規定以行政罰之手段禁止性交易行為，聲請人主張該規定違反比例原則侵害人民之人身自由及財產權，並有違平等原則，大法官經審理後，認該規定僅處罰意圖得利之一方，而不處罰支付對價之相對人，並以主觀上有無意圖得利作為是否處罰之標準，法律上已形成差別待遇，確實有違平等原則，故認其違憲並限期失效。

大法官於本號解釋中，係以憲法第 7 條之平等權作為核心審查基礎，僅處理該規定處罰對象的平等問題，完全規避該規定可能涉及性工作權或性自主權之部分。但有多位大法官均對本號解釋提出意見書，抨擊多數意見對人民性自主權的刻意忽略，林錫堯、陳敏、陳春生三位大法官共同提出之協同意見書即提出「是否基於對價關係而從事性行為」亦應被認為是性自主權的一部分，而陳新民大法官亦於其協同意見書中將本號解釋與先前同樣涉及「性自主行為」之釋字第 554 號解釋及釋字第 617 號解釋進行連結，前者肯認我國憲法保障性自主之權利，後者則強調性自主行為不論營利與否，均受憲法保障。

（四）釋字第 791 號解釋

釋字第 791 號解釋再度處理刑法第 239 條規定之通姦罪是否違憲，大法官重新檢視後，認該規定對人民性自主權之限制已不符比例原則，故宣告該規定違憲並立即失效。

大法官於本號解釋中，直接闡明性自主權受我國憲法保障，將釋字第 554 號解釋中「個人得自主決定是否及與何人發生性行為之自由」進一步擴大為性自主權之內涵定義，且認為性自主權與個人之人格有不可分離之關係，為個人自主決定權之一環，與人性尊嚴密切相關，並同樣將其定位為憲法第 22 條所保障之概括基本權。本號解釋首次明確承認性自主權為憲法位階之獨立基本權，並於利益

¹¹ 社會秩序維護法第 80 條第 1 款：「有下列各款行為之一者，處新台幣三萬元以下罰鍰：一、從事性交易。但符合第九十一條之一第一項至第三項之自治條例規定者，不適用之。」；釋字第 666 號解釋作成時適用民國 80 年制定之版本，同法第 80 條第 1 項第 1 款：「有左列各款行為之一者，處三日以下拘留或新臺幣三萬元以下罰鍰：一、意圖得利與人姦、宿者。」

衡量後，選擇保障人民之性自主權而宣告法規違憲，確立性自主權於我國憲法之地位。

二、大法官運用的解釋方法分析

從釋字第 554 號解釋首次提出「性行為自由」，到釋字第 791 號解釋的「性自主權」，大法官於不同解釋（包含意見書）中以不同角度及切入點詮釋性自主權，以下將嘗試歸納並分析本文認為大法官用於解釋性自主權的解釋方法，並解讀該解釋方法對我國性自主權起到何種作用。

（一）概括基本權的解釋局限

欲以憲法解釋方法討論性自主權，自然難以跳脫文本主義以及與其緊密相連的原旨主義，尤其文義解釋作為憲法解釋之起點與終點，然而性自主權本身並非憲法條文中明文列舉之基本權，僅係憲法第 22 條的概括基本權，此類與時俱進產生的新型態基本權較難以文本主義與原旨主義解釋或推導，若要強行適用反將面臨解釋困境。

1. 文本主義（Textualism）

文本主義的核心主張在於憲法解釋應受憲法條文的嚴格限制，認為唯有透過文本的客觀文義，才能克制司法權並維繫民主正當性，因此文本主義者常將憲法文本視為文義不應隨時代更迭的法律文件。文本主義的知名奉行者 **Black** 大法官就主張憲法權利只能是憲法文本中所列舉的那些，認為由非經選舉產生的法官，去「發明」憲法文本規定之外的權利來對抗多數政府，本身即是不民主的¹²。

美國憲法亦存在與我國憲法第 22 條規定相似的第九修正案：「憲法對於某些權利的列舉，不得被解釋為否定或貶低人民所保留的其他權利。」多人對將其理解為美國人的權利除了條文列出的之外，還包含其他額外的權利。**Douglas** 大法官也在 **Griswold v. Connecticut** 案中援引第九修正案來證成美國憲法保障隱私權，但 **Black** 大法官仍以「隱私權未在憲法文本中列舉」為由，強烈地表示異議。

觀諸我國憲法本文及增修條文之字面，皆未出現「性」、「性自主」或「性行為自由」等字樣，因此在最純粹的文本主義框架下，大法官若欲僅憑憲法第 22 條的概括條款承認一項憲法未明文的權利，必然面臨如 **Black** 大法官所指控的司法造法。若堅持單純以文本主義，性自主權極有可能因為在憲法文本中缺乏明文

¹² Sotirios A. Barber & James E. Fleming, *Constitutional Interpretation: The Basic Questions*, 68-69, 2007.

支撐而被排除在最高位階的憲法保障之外。

2. 原旨主義 (Originalism)

文本主義在實際運作上經常與原旨主義合流，認為必須探求憲法條文通過時，當代大眾所理解的普遍字面意義 (the original public meaning)，要求司法權在解釋憲法時，必須忠實於制憲者 (Framers) 或批准者 (Ratifiers) 在制憲當時的「原始意圖 (original intentions)」或「原始理解 (original understandings)」¹³。狹義原旨主義更主張若制憲者當時未曾意圖將某種行為納入憲法保障，司法者即不得逾越此一歷史事實。

若將狹義原旨主義適用於我國憲法第 22 條對性自主權的解釋，條文中「不妨害社會秩序公共利益」的要件將直接扼殺該基本權的存在正當性。我國憲法制定於民國 35 年，當時的起草者在構思第 22 條的概括基本權時，其具體意圖應集中於保障人民在經濟、社會或一般的生存自由，顯然不可能預見「個人對性行為的絕對支配權、通姦除罪化、或是多元性傾向認同」等現代性自主權範疇。反之，當時的刑法早已將通姦、娼妓與猥褻物傳播定為犯罪，這些管制才符合制憲當時的「社會秩序公共利益」。

(二) 大法官解釋方法的運作模式

1. 文本主義與原旨主義

大法官對文本主義與原旨主義的運作模式，比起用來「解放」性自主權，反而更容易作為「限制」性自主權的強大工具。於釋字第 554 號解釋中，大法官便強調依憲法第 22 條規定受保障之性行為自由，亦應同受「於不妨害社會秩序公共利益之前提」拘束，將婚姻與家庭制度與社會秩序畫上等號，其存續係為公共利益，從而論證性行為之自由應受婚姻與家庭制度之制約。

而同樣處理通姦罪的釋字第 791 號解釋，解釋文及理由書均絲毫未提及憲法第 22 條所附加之前提要件，大法官選擇閃避論證「有配偶之人與人發生性行為（通姦）是否不妨害社會秩序公共利益」。吳陳銀大法官則於其提出之不同意見書痛斥通姦之性行為自由的行使結果，將妨害一夫一妻婚姻制度、男女平等、家庭制度、子女正常成長及國家社會安定，不符合憲法第二十二條「不妨害社會秩序公共利益」的要件，不應受憲法所保障¹⁴。

¹³ Sotirios A. Barber & James E. Fleming, *Constitutional Interpretation: The Basic Questions*, 79, 2007.

¹⁴ 參見釋字第 791 號解釋吳陳銀大法官提出之不同意見書（第 2-4 頁）。

學者薛智仁亦提出，僅管從基本權理論來看，不宜承認基本權的內在界限，但是根據法條文義和體系，憲法第二十二條係以「不妨害社會秩序公共利益」作為未明文基本權的內在限制，此一制憲者的意思無法被視而不見，為避免發生不當限制自由的危險，只能對於此一要素作最嚴格的解釋——除非特定行為根本上牴觸憲法價值或有重大社會損害性，否則應從寬肯定其受基本權所保護¹⁵。

2. 共識主義 (Consensualism)

共識主義主張憲法的生命力並非凝固於過去，司法權在面對疑難案件 (hard cases) 時，應斟酌並反映當前社會對於該項權利詞彙意義的「當前共識 (current social consensus)」透過與時俱進的社會主流價值，來賦予釋憲者擴張保障新型態基本權的民主正當性。

縱觀我國性自主權的發展，共識主義可以說是貫穿全文，甚至可追溯自民國 23 年立法院修改刑法通姦罪時引發之激烈論辯。彼時對於通姦罪只處罰有夫之婦而不處罰有婦之夫，要求女性負片面貞操義務，透露出當時的社會風氣社經地位較高的已婚男子有婚外性活動並不受譴責。婦女團體對此不滿，要求改為無論有夫之婦或是有婦之夫與人通姦者均應受處罰，以實現男女平等之精神。由此引發男性立委與婦女團體間不同立場之攻防¹⁶，在婦女界之壓力下不得不決議要求立法院復議，然其提出的新草案雖將原本的「有夫之婦」改為「有配偶之人」，刑罰處罰仍僅適用於「相姦者」，按當時社會風氣，出軌者以男性佔絕大多數，由此可見男性立委抗拒處罰出軌男人之意志，直至立法院大會才確定修正為「通姦、相姦者並罰」。

立法機關將通姦罪規定於妨害婚姻及家庭罪中，無論學術及實務界多認其旨在維護婚姻生活及家庭制度，最終目的在於保護社會之善良風俗¹⁷。直至民國 91 年作成釋字第 554 號解釋時，大法官仍秉持通姦罪之存在有助於促使信守夫妻義

¹⁵ 薛智仁，通姦罪之憲法審查——評司法院釋字第 791 號解釋，成大法學，42 期，頁 17-18，2021 年。

¹⁶ 參見釋字第 791 號解釋黃瑞明大法官提出、詹森林大法官加入之協同意見書。頗為有趣者係，彼時因正反雙方僵持不下，通姦男女皆罰之草案於二讀表決結果未獲通過，反而通過將只處罰女性通姦罪之刑法條文刪除，而未定新條文，亦即無論男女通姦僅負民事責任，而不受刑法處罰。倘若當年依照二讀通過之草案完成立法，即不論男女通姦均不受刑事處罰，則釋字 791 號釋憲之結果早在當時就已實現，成為超前立法。

¹⁷ 鄭錦鳳，論通姦除罪化——兼評大法官釋字第 554 號解釋，軍法專刊，55 卷 5 期，頁 18，2009 年。

務成為社會生活之基本規範，增強人民對婚姻尊重之法意識及維護婚姻與家庭制度之倫理價值，且立法機關對夫妻忠誠義務所為評價無違一般社會通念。

但共識主義也有受到質疑的時候，若社會真的存在高度清晰的共識，則該案件根本不會成為需要大法官介入的「疑難案件」。同樣以性自主權為例，釋字第 617 號解釋涉及的猥褻物品管制和釋字第 666 號解釋涉及的娼嫖處罰爭議，社會大眾在性道德、性別剝削與言論自由之間，本就存在著劇烈的價值撕裂。當社會並無共識、甚至共識處於高度極化與衝突時，大法官宣稱的「社會共識」，就有可能只是司法者選擇性採納特定群體意見的修辭，缺乏客觀的實證基礎。

於釋字第 666 號解釋中，在當時社會普遍對性工作者抱持歧視與污名，缺乏保障共識的情況下，大法官若採取純粹的共識主義，斷不可能做出違憲宣告，但大法官僅處理平等權而將性自主權（包含性工作權）排除在外，難謂其未受社會共識影響。

3. 哲學方法（the Philosophic Approach）

哲學方法的核心主張認為憲法是一份由抽象抱負與理想所構成的「盟約（covenant）」。當憲法使用如「自由」、「人格」等高度抽象的詞彙時，其所指涉的，是這些概念本身的「真實含義（true meaning）」或「最佳解讀（best interpretation）」，而非制憲世代或當代社會某個特定群體的片面理解¹⁸。因此，司法者的職責在於進行「道德探究（moral inquiry）」，自行思考憲法條文背後的規範性價值，並在每一個當代個案中，努力詮釋並實踐這份盟約的完整含義。而此種解釋方法，與「性自主權」作為一項新型態的概括基本權具有天然的本質契合。

在釋字第 791 號解釋中，大法官之所以能推翻釋字第 554 號解釋，並非在民國 35 年的制憲檔案裡找到了新的解釋空間（原旨主義），也非因社會大眾已全面接受婚外性行為（共識主義），其論證的關鍵便是採取了哲學方法，大法官對人性尊言進行了道德層面的思考，多數意見不再以傳統的婚姻家庭制度來閹割個人，而是將「個人人格之自主發展與人性尊嚴之維護」提升至憲法最核心的指導原則。這正是 Barber 與 Fleming 所主張的哲學態度：司法者必須接受憲法文本中蘊含的道德證成，並透過公開的理性辯論，讓基本權保障朝向更偉大、更完整的自由層面邁進¹⁹。

¹⁸ Sotirios A. Barber & James E. Fleming, *Constitutional Interpretation: The Basic Questions*, 155, 2007.

¹⁹ Sotirios A. Barber & James E. Fleming, *Constitutional Interpretation: The Basic Questions*, 170, 2007.

肆、未來對性自主權之態度

一、無法擺脫的解釋困境

如前文所述，大法官轉向以哲學方法解釋性自主權，無疑為性自主權在未來的發展，開創了極為寬廣的憲法保障空間，幾乎可以預測未來再遇到性領域相關的憲法議題，大法官將在法理上持續論證性自主權作為人格不可或缺之核心，然而縱使能以哲學方法將性自主權「極大化」，卻依然無法徹底迴避文本主義的防線，尤其是憲法第 22 條本身明文內建的「不妨害社會秩序公共利益」之字面界限。在文本主義視角下，這項「不妨害社會秩序公共利益」的附加要件絕非具文，而是制憲者在文本上明確劃定、釋憲者在解釋時不可跨越的擋板。釋字第 617 號因涉及言論及出版自由而未直接適用此項要件，但大法官也有相關論述，性言論之表現與性資訊之流通可能有害社會多數人普遍認同之性觀念或性道德感情，至於是否有害，可能隨社會發展、風俗變異而有所不同，為後續保留解釋空間。

當未來社會面對更加前衛、極端或多元的性領域實踐議題²⁰時，大法官若繼續採取哲學方法，必然會主張這些新興性實踐攸關個人內在性別認同與生命幸福的自我定義，屬於人性尊嚴的範疇。若性自主權持續擴張，大法官無法再像過去釋字第 791 號解釋般僅用「婚姻所承載之社會功能則趨於相對化」之論述來迴避正面回應「社會秩序公共利益」此項要件。

而比憲法第 22 條「社會秩序公共利益」更為棘手且於實務上更具實質限制力的，乃是隱含於我國整體法律結構或立法目的中，高度抽象的「善良風俗」，儘管「善良風俗」多見於非憲法位階的法律文本中，但它實質上扮演著界定「社會秩序與公共利益」憲法內涵的關鍵因素。過去大法官在釋字第 554 號、第 617 號等解釋中，之所以將通姦行為或非主流性言論排除在受保障的自由之外，其本質上皆是將當時保守的、由異性戀單偶婚保障制度所定義的「善良風俗」，等同於憲法上的「公共利益」。故未來性自主權的發展道路上，如何處理「社會秩序公共利益」以及「善良風俗」的解釋，將是大法官最大的挑戰。

二、可能的解釋方向預測

（一）釋字 617 號解釋與釋字 666 號解釋的再續

現行刑法第 235 條所受規範的章名仍為「妨害風化」，其立法目的應在保護

²⁰ 諸如非傳統親密關係的法律承認、商業性交易的合法化、或新興性科技與深偽性私密影像的管制。

善良風俗，但善良風俗如果不能被具體闡明「善良」的理由，指出行為具體的利益或不利益，則以善良風俗作為該犯罪類型的保護法益，將成空洞的循環論證²¹。

釋字第 666 號解釋僅處理平等而未從自由權著手審查，即不免衍生出新法適用上的關鍵爭議：究竟在我國憲法秩序下，人民是否有從事性交易或是以性作為對價之自由，此一自由保障的問題並非單純僅處理平等與否所能回答。由平等原則僅能推導出雙方均應或均不應處罰，仍需藉助自由權審查始能得出「不應處罰」之誡命規範²²

（二）侵害性自主權的認定與加重刑罰

性自主權地位的提升，不僅保障人民的積極性自主權，使人民有權依據自我的人格發展與幸福定義，積極地去追求、形塑個人性領域並加以實踐；與此同時，性自主權同樣具備了強烈抗拒外在侵犯的「消極性自主權（防禦功能）」。

此面向的核心在於保障個人對於自身性領域的絕對支配權與不容侵犯性，任何未經個人自主同意的性接觸、性窺探或性剝削，皆是對人性尊嚴最直接的踐踏。

伍、結論

本篇報告藉由 Barber 與 Fleming 的憲法解釋方法論，系統性檢視我國性自主權之釋憲流變與未來展望，並嘗試提出本文見解。

回看本文於前言提出之爭點，本文認為性自主權已非僅止於「個人與何人、在何時、以何種方式發生性行為」此種消極不受干預的身體行為自由，而係「個人於性領域之自主決定權」。又性自主權作為一項並未明文見於憲法文本的概括基本權，透過釋字第 791 號解釋完成的「人性尊嚴與個人主體性」典範轉移，已證明在面對通姦、性交易等價值極化的疑難案件時，司法者無法躲在歷史意圖或多數民意背後，必須採取哲學方法，對憲法抽象詞彙進行道德探究與「最佳解讀」，故哲學方法是解釋新型態基本權的一大利器。

然哲學實踐亦無法脫離文本主義的制約，未來性自主權的擴張，必然面臨憲法第二十二條「社會秩序公共利益」與法律上「善良風俗」的字面限制。司法者必須以「危害原則」進行去道德化的限縮解釋，唯有在客觀上實質侵害他人權利

²¹ 黃榮堅，對於性交易的刑法觀點——兼評大法官釋字第 623 號解釋，政治與社會哲學評論，23 期，頁 194，2007 年。

²² 張志偉，再訪釋字第 666 號解釋，收於：如沐法之春風——陳春生教授榮退論文集，頁 85，2020 年。

時方得限制，確保哲學方法的實質正義仍能立足於文本框架中。又性自主權兼具積極建構與消極防禦雙重面向，未來在侵害認定上，應擺脫對物理強制的依賴，轉向以「違反意願」為核心，深化消極防禦功能。

綜上所述，本文對我國性自主權的未來之預測，應係在文本框架下繼續深化哲學方法，並於實體制度中平衡積極自由與消極防禦，方能真正落實性自主權所欲達成人性尊嚴與人格自由發展憲法價值。

參考文獻

專書論文

張志偉，再訪釋字第六六六號解釋，收於：如沐法之春風—陳春生教授榮退論文集，頁 78-107，2020 年。

期刊論文

黃榮堅，對於性交易的刑法觀點—兼評大法官釋字第 623 號解釋，政治與社會哲學評論，23 期，頁 179-219，2007 年。

葉啟洲，通姦罪違憲論的初始觀點—大法官釋字第 554 號解釋的聲請典故，台灣法學雜誌，392 期，頁 43-47，2020 年。

鄭錦鳳，論通姦除罪化—兼評大法官釋字第 554 號解釋，軍法專刊，55 卷 5 期，頁 12-22，2009 年。

薛智仁，通姦罪之憲法審查—評司法院釋字第七九一號解釋，成大法學，42 期，頁 1-69，2021 年。

外文文獻

Sotirios A. Barber & James E. Fleming, Constitutional Interpretation: The Basic Questions, 2007.